

1500579-51.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... o acusado como o responsável pelo tráfico de drogas na região e não foram avistadas condutas prévias que indicassem o envolvimento do acusado no tráfico de entorpecentes (p. ex., recebimento de dinheiro, entrega de objetos, etc.), além de não terem sido apresentados outros indivíduos como possíveis compradores das drogas e/ou testemunhas presenciais dos fatos. Além disso, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500579-51.2022.8.26.0599 - Controle nº 2022/000482

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108036/2022 - 05º D.P. PIRACICABA, 24431107 - 05º D.P. PIRACICABA, 2108036 - 05º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL AGUIAR SILVA

Réu Preso

Aos 06 de setembro de 2022, às 15:00h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao disposto no Provimento CSM 2651/2022, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: GABRIEL AGUIAR SILVA - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC FRANCISCO DERNIVAL MIRANDA JÚNIOR - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC CESAR EDUARDO BOTTENE - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foi colhido o depoimento da testemunha GC FRANCISCO DERNIVAL MIRANDA JÚNIOR.

Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha GC CESAR EDUARDO BOTTENE, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha GC CESAR EDUARDO BOTTENE, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Após, o réu GABRIEL AGUIAR SILVA foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "GABRIEL AGUIAR SILVA, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória de fls. 77/79. O processo teve andamento regular. Devidamente notificado (fls. 102), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 105), sendo a denúncia recebida (fls. 107/109). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu, por fim, interrogado. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 64/67. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O guarda municipal Francisco Dernival Miranda Júnior, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que estavam em patrulhamento pelo bairro Boa Esperança, quando, no local dos fatos, avistaram o acusado em atitudes suspeitas, eis que mexia em uma lixeira, tendo ele apresentado bastante nervosismo ao ver a viatura, motivo pelo qual resolveram abordá-lo. Disse que, ao ser submetido a uma revista pessoal, foram encontradas em poder do réu 02 pedras de "crack", 08 porções de cocaína e 07 porções de maconha, além da quantia de R\$ 69,00 em espécie. Afirmou que fizeram uma busca no local e na lixeira onde o acusado estava em contato, encontraram outras 12 pedras de "crack", 19 porções de cocaína e 82 de maconha, as quais estavam embaladas de forma idênticas às que foram localizadas em poder do réu. Relatou que, no momento da localização das porções em poder do acusado, ele disse, de forma informal, que estava no local traficando drogas, assumindo também a propriedade das porções localizadas na lixeira. No mesmo sentido foram as palavras do guarda municipal César Eduardo Bottene, ouvido apenas na fase policial. Por fim, interrogado, o réu negou os fatos a si atribuídos, alegando que estava de folga do trabalho e foi até a biqueira comprar drogas para seu uso. Disse que comprou três capsulas de cocaína e entregou-lhe o dinheiro, pagando dez reais cada pino, recebendo setenta reais de troco, momento em que os guardas chegaram e o abordaram, tendo o traficante corrido. Disse que os guardas viram que ele estava apenas com 3 pinos de cocaína, e lhe disse que eram destinados ao seu uso. Os guardas pediram que ele lhes levasse até o traficante, o que negou, tendo então os guardas o levado preso. Entretanto, em que pese a negativa do réu quanto aos fatos, sua versão não deve prevalecer, vez que dissonantes e isoladas das demais provas coligidas nos autos, não encontrando nelas qualquer respaldo. De fato, insta ressaltar que, em que pese a alegação do acusado no sentido de que era apenas usuário não tem como prevalecer, eis que os guardas não viram ninguém mais no local, não tendo visto ninguém correndo e, por outro lado, viram o acusado mexendo na lixeira onde o restante das drogas foi localizado e apreendido. Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos guardas são plenamente válidos como meio de prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela. Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC nº 123293/MS, publicado no dia 16/11/2009, do qual se extrai o seguinte trecho: O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a

condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. Ainda nesse sentido: PROVA - TESTEMUNHA - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - O testemunho de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como de qualquer outro testemunho - Merecem credibilidade e se de acordo ou conformidade com as demais provas, justificam um decreto condenatório - Entendimento - Precedentes - Recurso parcialmente provido. (Apelação n. 990.08.180251-1 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton de Oliveira Neves - 04/05/2010 - 8640 - Unânime). (Grifei). Destarte, tem-se que o crime descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor. Quanto à aplicação da reprimenda, verifica-se que as circunstâncias judiciais são neutras. Na segunda fase, observa-se que o réu é reincidente específico (autos nº 0000407-96.2016 - fls. 82/83). Na terceira fase, ante a reincidência, inaplicável o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Requeiro, por fim, seja decretado o perdimento do valor apreendido com o acusado, consistente em R\$ 69,00 (sessenta e nove reais), com fulcro nos artigos 61 e 63, ambos da Lei nº 11.343/2006. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da exordial".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende, EM SEDE PRELIMINAR, que as provas obtidas nos autos, em especial as substâncias entorpecentes encontradas pelos Guardas Municipais são ilícitas, eis que a abordagem e a prisão do acusado decorreram de autoridades incompetentes. Com efeito, de acordo com a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 144, § 8º, os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, sendo o referido dispositivo reproduzido de forma idêntica na Constituição do Estado de São Paulo. Portanto, de acordo com as referidas disposições, vislumbra-se que a atual ordem jurídica contempla quais são as específicas atribuições da Guarda Municipal, órgão ao qual incumbe a defesa e proteção dos bens, serviços e instalações em âmbito municipal. Ou seja, as Guardas Municipais não têm status de polícia ostensiva, função esta que cabe a Polícia Militar do Estado de São Paulo. No caso em tela, verifica-se que houve flagrante invasão de competência material, pois a Guarda Municipal atuou como se fosse polícia ostensiva. Nesse aspecto, cumpre mencionar que os Guardas, de forma ilegal, abordaram o acusado e efetuaram a sua revista pessoal sem que qualquer situação de flagrante delito estivesse visível e somente porque estavam "em patrulhamento" no local dos fatos e o réu apresentou "nervosismo" ao ver a viatura, ainda que não houvesse qualquer bem ou serviço a ser resguardado na região e, também, que fossem autoridades incompetentes para tanto. Essa função, todavia, não incumbe aos Guardas Municipais, mas à Polícia Militar. Na realidade, os Guardas Municipais, diante do fato, deveriam ter acionado o órgão competente para atender à ocorrência. Na atual ordem jurídica, existe a polícia ostensiva, representada pela Militar, e a polícia judiciária, representada pela Civil. Assim, os Guardas jamais poderiam ter atuado como se possuíssem aptidão para tanto. Há, no caso em comento, evidente invasão de competência administrativa, de índole constitucional, o que enseja a ilegalidade do ato (prisão em flagrante) e de todas as provas carreadas aos autos, visto que elas são provenientes, todas, de atos dos aludidos Guardas Municipais que atuaram como polícia ostensiva, em flagrante desrespeito às suas atribuições constitucionais. Neste sentido, já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "Ação Penal - Desarmamento - Guarda Municipal - Ação de polícia ostensiva - Ilegalidade - Apelo provido para absolver o acusado." (TJSP, ACri nº 990.09.226504-0 - 2ª câmara de direito criminal - origem: Piracicaba/SP, julg. 1º/02/10); "Apelação Criminal Tráfico de entorpecentes - Prisão dos réus efetuada por Guardas Municipais - Afirmação dos servidores da realização de campanha para confirmar o crime - ilegalidade da ação reconhecida - Admissão, no caso

presente, da existência de prova que contamina a ação penal Apelo provido para absolver os réus." (TJSP, ACri nº 0032340-54.2011.8.26.0602 - 2ª Câmara de Direito Criminal - origem: Sorocaba/SP, julg. 12/11/2012). Inclusive, nas palavras do Ilustre Desembargador relator da Apelação Criminal nº 0032340-54.2011.8.26.0602, cuja ementa se encontra acima transcrita e que teve origem na Comarca de Sorocaba/SP, onde também é usual que a Guarda Municipal exerça as tarefas da polícia ostensiva, defendeu, com grande propriedade, o Dr. Almeida Sampaio: "Fica delineado, de maneira bastante evidente, portanto, que, dentro da divisão das atribuições das Polícias, somente à Militar é outorgado constitucionalmente o poder de exercer o policiamento ostensivo, cabendo tão-somente à Guarda Municipal a proteção de seus bens, serviços e instalações". E ainda: "Em razão da Constituição de 1988, todos os entendimentos jurisprudenciais e a legislação que não se coadunem com a norma perderam sua validade. Enquanto não ocorrer alteração dos dispositivos acima transcritos, fica rejeitada a validade da ação de Guarda Municipal que, em ação de policiamento ostensivo, efetua diligências para prender eventual traficante.". No mais, corroborando esse entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, durante julgamento emblemático proferido no REsp nº 1.977.119/SP (2021/0391446-0), definiu exatamente quais são as atribuições da Guarda Municipal na ordem jurídica brasileira, deixando claro que não é função da referida Instituição patrulhar eventuais "pontos de tráfico de drogas", realizar abordagens e revistas pessoais de indivíduos suspeitos ou investigar denúncias anônimas relacionadas ao comércio de entorpecentes ou outros delitos cuja prática não atinja de maneira evidente e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Além disso, restou expressamente consignado no v. acórdão que o flagrante previsto no artigo 301 do Código de Processo Penal não autoriza a atuação desenfreada da Guarda Municipal e a realização de todo e qualquer tipo de abordagem ou busca pessoal. A norma em questão permite somente a prisão nos casos dos flagrantes visíveis "de plano", o que não é o caso de situações em que o delito só se evidencia após atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa, como busca pessoal ou domiciliar. E, por fim, a r. decisão também observou que, diante da natureza sui generis dos Guardas Municipais, a eles é atribuída, na verdade, a função de coibir os casos de flagrante delito vinculados à sua função específica, qual seja, a tutela dos bens, serviços e instalações do Município, situação na qual o tráfico de drogas, geralmente, não se enquadra. Todavia, se superada a preliminar, QUANTO AO MÉRITO, as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao denunciado. Isso porque, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Francisco, GCM, declarou que passavam pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Visualizaram o réu mexendo em uma lixeira. Ao ver a equipe, ele ficou nervoso, o que motivou a abordagem. Com o réu, encontraram uma quantidade de maconha, cocaína e crack, além de uma quantia em dinheiro. Efetuaram buscas na lixeira onde o réu estava mexendo e encontraram o restante das drogas. O acusado confessou informalmente o tráfico. Todas as drogas estavam embaladas da mesma forma. O réu, em interrogatório, declarou que reside na Rua Murici, no número 85. Trabalha como ajudante de pedreiro junto com seu pai. No dia dos fatos, estava de folga e foi comprar drogas para seu consumo pessoal. Comprou 03 porções de cocaína e recebeu o troco. Quando estava indo embora, os Guardas chegaram. O traficante saiu correndo e os Guardas o abordaram. Eles queriam que o acusado informasse onde o traficante morava. Como se negou a dizer, os Guardas o algemaram e o colocaram na viatura. Pagou R\$ 10,00 por cada cápsula de cocaína. Estava com R\$ 70,00 de troco. Já conhecia os Guardas, eles o abordaram em uma ocasião anterior quando estava fumando maconha com sua esposa e houve um desentendimento com eles. Portanto, Excelência, verifica-se que o acusado nega a prática do tráfico de drogas, sendo que sua negativa deve ser considerada um elemento probatório, afastando-se qualquer juízo preconceituoso que se tenha contra ela, sobretudo porque não refutada pelas demais evidências dos autos. Isso porque, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos Guardas Municipais responsáveis pela prisão do acusado, as quais, todavia, devem ser

recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança patrimonial do Município ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem em Juízo a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras de Policiais ou outros agentes de segurança como fundamento para uma condenação: "Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger." (TJSP – 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin – j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito do depoimento

dos Guardas, não existiam sequer denúncias prévias apontando o acusado como o responsável pelo tráfico de drogas na região e não foram avistadas condutas prévias que indicassem o envolvimento do acusado no tráfico de entorpecentes (p. ex., recebimento de dinheiro, entrega de objetos, etc.), além de não terem sido apresentados outros indivíduos como possíveis compradores das drogas e/ou testemunhas presenciais dos fatos. Além disso, a maior parte dos entorpecentes não estava sob a posse direta do acusado, mas em um local aberto, de livre acesso a qualquer indivíduo. E a suposta confissão informal do acusado não foi confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Portanto, diante das provas produzidas, a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [15:59] Rafael Bresciani Marracini Entretanto, na hipótese deste E. Juízo afastar o pleito absolutório, requer-se, ao menos, diante das declarações do acusado em seu interrogatório, a DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. Isso porque, com a devida vênia, há de se reconhecer que não há nos autos indícios de que o acusado fosse comercializar as drogas apreendidas em seu poder, sendo que, reitera-se, não foi verificado qualquer ato efetivo de mercancia dos entorpecentes. Assim, no máximo, o réu poderia ser responsabilizado por portar drogas para fins de consumo pessoal, pois não foi demonstrado cabalmente o intuito lucrativo, não bastando a simples apreensão do entorpecente em poder do acusado para se justificar uma condenação por tráfico. Vale observar, ainda, que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas em poder do réu nada diz quanto à sua destinação, eis que a quantidade necessária para a satisfação de um usuário é completamente variável. Para a configuração do crime de tráfico, não basta a simples apreensão da droga, sendo imprescindível a aferição de prova cabal da finalidade de mercancia dos entorpecentes por parte do réu, o que não foi o caso. Entretanto, na hipótese deste E. Juízo afastar o pleito absolutório, requer-se, ao menos, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º,

DA LEI Nº 11.343/06, MESMO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. Isso porque, ainda que considerado reincidente, vale lembrar que a Lei de Drogas, ao fixar como pena mínima, para o delito de tráfico, cinco anos de reclusão, prevendo, ainda, a causa de diminuição de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para primários, acaba por valorizar, em demasia, o critério da reincidência. Desde, portanto, que presentes os outros requisitos para a aplicação da causa de diminuição (ou seja, não havendo elementos probatórios de que o réu se dedique ao crime, praticando-o com contumácia, e sem provas de que ele integre organização criminosa), é de se considerar que o peso atribuído à reincidência é superdimensionado em relação ao apenamento do agente primário, ofendendo, assim, o princípio da proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional do Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF). A aplicação da pena ao réu primário, presentes os demais requisitos legais, ensejaria a redução no patamar de 2/3, implicando a sanção de um ano e oito meses de reclusão. Ao réu reincidente, o mesmo fato representaria, pela ausência de aplicação da causa de diminuição, uma pena de 5 (cinco) anos. O peso da reincidência, portanto, é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 (um terço) da pena, sendo 2/3 (dois terços) aplicados em função da reincidência. Essa desproporção também é inconstitucional porque atribui, para a dosagem da pena, valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência implica a aplicação do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (ou seja, em face de seus antecedentes) e não em função do ato por ele praticado. Como afirma Muñoz Conde: “A distinção entre Direito Penal do ato e Direito Penal do autor não é só uma questão sistemática, mas, também, e fundamentalmente, política e ideológica. Só o Direito Penal baseado no ato cometido pode ser controlado e limitado democraticamente (...) o Direito Penal do autor não permite limitar o poder punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária” (Teoria Geral do Delito – SAFe, p. 09/10). O direito penal do autor não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e por isso suas impressões devem ser descartadas, inclusive pelo Juiz. No mesmo sentido: “O direito penal de autor não encontra guarida em nenhum sistema penal fincado no Estado de Direito, comprometido, que é, com a dignidade da pessoa humana e com a garantia de seus direitos fundamentais, e, sobretudo, em nosso ordenamento, onde a presunção vigente é, ao reverso do que se propugna com a referência a tal condenação, a de inocência.” (Min. Cezar Peluso em Voto Visto no RHC 81.057-8-SP). Por fim, nem se diga da impropriedade de se afastar uma regra legal (proibição da redução ao reincidente) em face de um princípio não explícito. Como afirma Fábio Konder Comparato, apesar de seu alto grau de abstração, os princípios são normas jurídicas e não simples recomendações programáticas ou exortações políticas. Mais ainda: trata-se de normas jurídicas de eficácia plena e imediata, a dispensar a intermediação de regras concretizadoras. Provocado ou não pelas partes, o juiz está sempre autorizado a aplicar diretamente um princípio ao caso trazido ao eu julgamento, por força do disposto no §1º do art. 5º, da Constituição (“O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos”, in Direitos Humanos – Visões Contemporâneas, edição de Associação Juízes para a Democracia, 2001). Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, sendo que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao acusado, ressaltando-se que a sua vida pregressa deve ser valorada somente na segunda fase, a fim de se evitar eventual bis in idem com eventual agravante da reincidência; (ii) a incidência, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea (ainda que informal), compensando-a com eventual agravante da reincidência, diante do caráter subjetivo e preponderante de ambas as circunstâncias; (iii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iv) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº

8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF - Pleno - HC nº 111.840/ES - rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ; (v) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento processual, a manutenção de sua prisão preventiva".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

GABRIEL AGUIAR SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 20 de abril de 2022, por volta das 10h50min, na Rua Murici, nº 10, Bairro Vila Sônia, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, trazia consigo e tinha em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 89 (oitenta e nove) porções de maconha, pesando cerca de 129,2g (cento e vinte e nove gramas e dois decigramas), 27 (vinte e sete) eppendorfs de cocaína em pó, pesando, aproximadamente 7,3g (sete gramas e três decigramas), e 14 (quatorze) porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 0,7g (sete decigramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que guardas municipais estavam em regular patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram o acusado mexendo em uma lixeira em atitudes suspeitas. Em razão disso, os agentes da lei procederam à abordagem e apreenderam na posse de GABRIEL 02 porções de crack, 08 eppendorfs de cocaína em pó, 07 porções de maconha e a quantia de R\$ 69,00 em espécie. Ato contínuo, os guardas diligenciaram na lixeira onde o réu mexia anteriormente e apreenderam outras 12 porções de crack, 19 eppendorfs de cocaína em pó e 82 porções de maconha, embaladas de forma idêntica às encontradas na posse de GABRIEL. Indagado, o acusado confessou aos agentes públicos a prática delitiva.

O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 102) e apresentou defesa preliminar (fls. 105). Após, a decisão de fls. 107/109 recebeu a denúncia.

Designada audiência, foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia e, em seguida, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 64/67, que trouxe resultado positivo para maconha e cocaína.

A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu fez uso do direito de permanecer em silêncio (fls. 05)

Em juízo, negou a prática do crime. Disse que mora na Rua Murici, 85, e, no dia dos fatos, estava de folga. Asseverou que é usuário de cocaína e foi à biqueira, na esquina da sua casa. Alegou que comprou três cápsulas de cocaína e recebeu o troco. Declarou que deu uma nota de R\$ 100,00 e recebeu R\$ 70,00 de troco. Disse que os policiais chegaram e o moleque correu. Sustentou que os policiais não conseguiram pegar o moleque e o seguraram, dizendo que ele teria que indicar onde morava o traficante, mas falou que não sabia. Aduziu que os policiais disseram que seria dele o que encontrassem.

A prova produzida, porém, é maciça e incriminadora.

Com efeito, o guarda municipal Francisco relatou que passavam pelo local, bem conhecido como ponto de comércio de entorpecentes, e viram o réu mexendo numa lixeira. Atestou que, ao ver a presença da equipe, ele ficou bem nervoso e foi abordado. Disse que, com ele apreenderam porções de cocaína, crack e maconha, bem dinheiro, em notas trocadas. Aduziu que, na lixeira que ele mexeu, encontraram mais

porções das mesmas drogas, embaladas de forma idênticas às encontradas com ele. Atestou que o réu assumiu a propriedade de todo o entorpecente e a prática do tráfico.

No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal César Eduardo, ouvido à fls. 06. É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem guardas não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E “como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial” (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de guardas é tão válida quanta outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes.

Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665).

Por fim, não houve qualquer ilegalidade na conduta dos guardas municipais, já que, conforme dispõe a lei, qualquer do povo pode efetuar prisão em flagrante delito (art. 301 do Código de Processo Penal). Aliás, seria absurdo imaginar-se que os guardas municipais, informados da prática criminosa, não pudessem tomar providências para fazer cessar a infração, ficando, passivamente, no aguardo da chegada de policiais civis ou militares (cf. Apelação nº 0019493-07.2010.8.26.0068, Rel. Des. CESAR MECCHI MORALES, j. 16.12.14).

Confira-se, sobre o tema, o seguinte julgado: “Habeas Corpus – Tráfico de drogas– Pleito de revogação da prisão preventiva – Alegação de ilegalidade da prisão realizada por Guardas Municipais. Atuação dos Guardas Municipais. Ausente ilegalidade – Artigo 301 do CPP – Qualquer pessoa do povo pode, e as Autoridades policiais e seus agentes devem realizar prisões em flagrante - Crime de Tráfico de Drogas que, por ser delito permanente, tem a sua consumação protraída no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer momento. Jurisprudência do C. STJ. No caso em tela, ao que consta, o estado de flagrância se mostrou aparente, de modo que lícita foi a atuação dos Guardas Municipais, os quais, inclusive, devem zelar pela segurança social. No mais, eventuais irregularidades da prisão em flagrante restam superadas com a decretação da prisão preventiva do Paciente.

Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despacho suficientemente fundamentado. Paciente incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2014342-16.2022.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022).

Não bastasse essa orientação já consolidada na jurisprudência, há que se ressaltar que, conquanto não seja essa essencialmente sua função, o guarda municipal está autorizado por norma legal expressa a encaminhar à presença da autoridade policial indivíduos presos em flagrante delito, consoante a regra inscrita no artigo 5º, inciso XIV, da Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais).

Enfim, o fato de os guardas municipais terem apreendido em poder do acusado duas porções de crack, oito eppendorfs de cocaína e sete porções de maconha, além de



dinheiro em notas trocadas, bem como, no interior da lixeira em que ele mexeu, 12 porções de crack, 19 eppendorfs de cocaína e 82 porções de maconha, embaladas de maneira idêntica às encontradas com ele, o que não foi infirmado por nenhum elemento de prova, conduz à certeza quanto a autoria.

Prosseguindo, a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida e a forma como estavam acondicionados, aliados ao local dos fatos, conhecido ponto de tráfico, evidenciam que as drogas se destinavam ao comércio ilícito.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cabendo anotar que, para sua configuração, não se exige qualquer ato de venda, bastando, como no caso em tela, que o agente traga consigo ou tenha em depósito a substância entorpecente.

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo às circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, observo que o réu é reincidente, inclusive específico (fls. 82/83). Entretanto, essa circunstância só pode ser considerada na segunda fase de fixação da pena, evitando-se bis in idem. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no seu valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, está presente a agravante da reincidência, que é específica (processo nº 0000407-96.2016 desta 4ª Vara Criminal - cf. cert. de fls. 82/83), razão pela qual aumento a pena em um quinto, resultando seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes.

Inexistem causas de aumento e, por ser reincidente, não faz jus o réu à redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, em decorrência da reincidência específica e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a qual não pode ser tornada insubsistente, sobretudo em razão da superveniência de sentença condenatória pela prática de crime equiparado a hediondo.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça: "Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante

da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

Demonstrada a origem ilícita do dinheiro apreendido, declaro seu perdimento.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, CONDENANDO o réu GABRIEL AGUIAR SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, no valor unitário mínimo, fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena e vedado o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra preso e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Declaro perdido o dinheiro apreendido.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

A seguir, pela MMª. Juíza foi deliberado o seguinte:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do(a) Dr(a). Promotor(a), dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO.

2) Recebo o recurso interposto.

3) Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação.

4) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.

5) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória.

6) Com as razões e contrarrazões de apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 05/09/2034.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo

JUÍZA DE DIREITO

[Assinado eletronicamente]